

1502187-19.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... a causa especial de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V), lembrando-se que para sua caracterização "é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587, STJ).

Esse elemento por si só justifica aumento da pena em 1/5, acima da fração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502187-19.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502187-19.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229599/2021 - DEL.POL.ARUJA, 19806150 - DEL.POL.ARUJA, 1538/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2229599 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIMARIO NUNES DA COSTA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

FRANCIMARIO NUNES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c/c 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no 23 de agosto de 2021, por volta das 16h30min, na altura do Km 204 da Rodovia BR 116 (Rodovia Presidente Dutra), sentido Rio de Janeiro, Bairro Jardim Joia, nesta cidade e comarca de Arujá/SP, o indiciado FRANCIMARIO NUNES DA COSTA, transportava e trazia consigo, em transporte público, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) tijolos de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso total (líquido) de 50.400 g (cinquenta quilos e quatrocentos gramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão de fls. 06/07, laudo de Constatação de fls. 24/28 e

laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado" (fls. 52/54)
O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 34/38).
Foi notificado (fls. 87) e apresentou defesa prévia (fls. 97/100). Recebida a denúncia (fls. 103/105), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.
Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a aplicação da figura do tráfico privilegiado; a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais favorável.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos)

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal".

A pretensão punitiva é procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 2/4); auto de exibição e apreensão (fls. 6/7); laudo de constatação provisório (fls. 24/28) e laudo pericial definitivo (fls. 124/126), que atestam que a substância encontrada era de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (65 tijolos contendo 50,4 kg líquidos de maconha). Também não há dúvida da autoria.

A testemunha Israel Sampaio Moraes disse em sede policial "que estavam em diligências de rotina pelo local dos fatos acabaram realizando a abordagem em um ônibus que havia saído da Rodoviária Tietê/SP com destino ao estado do Espírito Santo. Informam que fizeram o procedimento de rotina, entrevistando todos os passageiros e assim se depararam com a pessoa de FRANCIMARIO, ora indiciado, visivelmente nervoso e que não estava conseguindo explicar ao certo para onde estava indo. Dessa forma, efetuaram a busca na mochila que estava entre as pernas dele e lá encontraram alguns tijolos de substância que aparentava ser maconha, e então com o auxílio de cães farejadores, foi encontrado nos pertences de FRANCIMARIO que estavam no bagageiro do ônibus, averiguando-se também a etiqueta da mala e da passagem, diversos tijolos de maconha (65 tijolos), sendo utilizados várias roupas para escondê-los, e posteriormente FRANCIMARIO confirmou que pertenciam a ele. Com ele também estava um telefone celular e um montante de R\$ 270,00. Ao ser indagado, o indiciado afirmou aos policiais que recebeu uma proposta de pessoa desconhecida na qual ele teria apenas que fazer o transporte das drogas até o Espírito Santo e que então receberia um valor de R\$ 5000,00. Diante do que foi dito e pelas provas apresentadas, foi dada a voz de prisão em flagrante delito e o indiciado conduzido a esta Delegacia de Polícia" (fls. 5).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que fazia fiscalização de rotina no pedágio de Arujá, deu voz de parada a um ônibus de linha, São Paulo - Espírito Santo. Fez a entrevista com o réu e negou nervosismo com desencontro de

informações. Tinha volumes nas pernas, o que gerou questionamento. O réu admitiu que estava levando maconha. Desceram com o réu, que informou que tinha bagagem no compartimento inferior. Embaixo outros colegas já tinham encontrado as malas dele com cães. Ele informou para equipe que subiu na rodoviária do Tietê e levaria até o Espírito Santo, mas não se recorda a cidade específica. Salvo engano, o réu disse que receberia R\$5.000,00.

A testemunha Victor Taver de Siqueira disse em sede policial "que estavam em diligências de rotina pelo local dos fatos acabaram realizando a abordagem em um ônibus que havia saído da Rodoviária Tietê/SP com destino ao estado do Espírito Santo. Informam que fizeram o procedimento de rotina, entrevistando todos os passageiros e assim se depararam com a pessoa de FRANCIMARIO, ora indiciado, visivelmente nervoso e que não estava conseguindo explicar ao certo para onde estava indo. Dessa forma, efetuaram a busca na mochila que estava entre as pernas dele e lá encontraram alguns tijolos de substância que aparentava ser maconha, e então com o auxílio de cães farejadores, foi encontrado nos pertences de FRANCIMARIO que estavam no bagageiro do ônibus, averiguando-se também a etiqueta da mala e da passagem, diversos tijolos de maconha (65 tijolos), sendo utilizados várias roupas para escondê-los, e posteriormente FRANCIMARIO confirmou que pertenciam a ele. Com ele também estava um telefone celular e um montante de R\$ 270,00. Ao ser indagado, o indiciado afirmou aos policiais que recebeu uma proposta de pessoa desconhecida na qual ele teria apenas que fazer o transporte das drogas até o Espírito Santo e que então receberia um valor de R\$ 5000,00. Diante do que foi dito e pelas provas apresentadas, foi dada a voz de prisão em flagrante delito e o indiciado conduzido a esta Delegacia de Polícia" (fls. 8).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que estava em fiscalização de rotina, entrevistando todos os passageiros. Segundo relato de outro colega, o réu não soube explicar o motivo da viagem, entrou em contradições, aparentando nervosismo, o que motivou busca nas bagagens. O depoente fez a busca da bagagem embaixo e em cima. Na mala de cima haviam algumas meias tampando os tijolos de maconha. Na debaixo tinha meia, mas em menor quantidade. Eram duas malas embaixo e outra mala. No momento o réu disse que um cidadão teria o abordado e pediu para fazer a viagem e iria receber um dinheiro. A linha do ônibus era São Paulo - Espírito Santo, mas não se recorda se o réu iria descer antes pela passagem. Foram encontradas maconha

O réu Francimario Nunes da Costa permaneceu em silêncio na fase policial. (fls. 13). Em Juízo, disse que nunca traficou. Apenas aceitou a proposta pois sua família estava passando necessidade. Trabalha como camelô, a prefeitura confiscou seu material. Conheceu uma pessoa no ferro velho, que mencionou que tinha um amigo que iria oferecer algumas viagens. Iria receber R\$5.000,00 para entregar a droga em Vitória - ES.

Embora a inocência deva ser presumida, ao final da instrução a acusação cumpriu seu ônus de demonstrar os fatos alegados na denúncia.

Com efeito, os policiais da PRF confirmaram em Juízo que em fiscalização de rotina abordaram o ônibus com destino ao Espírito Santo, no pedágio de Arujá. O réu aparentou nervosismo e com ele foi encontrada grande quantidade de droga na mala de cima e do bagageiro, mais de 50 quilos de maconha.

Não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Por isso, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente na forma a lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer elemento que contrariasse tais premissas, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156, CPP). Ao contrário, admitiu a prática do delito, confissão que está em conformidade com os demais elementos dos autos.

Ademais, o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga.

Mesmo a conduta de "oferecer" não exige a finalidade lucrativa, pois a lei tipifica as condutas praticadas "ainda que gratuitamente". Na realidade, o intuito de lucro é apenas uma circunstância negativa que justifica aumento da pena. Por isso, não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercancia. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam intenção de venda.

O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Feita essa ressalva, no caso concreto a quantidade não era compatível com a figura de mero usuário (50 kg de maconha), e o próprio réu admitiu que iria entregar a droga para terceiro. Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo abstrato entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 10 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

Nos crimes da Lei 11.343/06 merecem destaque ainda "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42). O réu é primário.

A quantidade de drogas (50 kg de maconha) autoriza o aumento da pena base, dado seu maior potencial destrutivo e viciante, acarretando igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los.

O crime se consuma por condutas realizadas "ainda que gratuitamente" (art. 33, "caput"). Por isso, aquele que visa a praticar atos de comércio ou promessa de recompensa financeira realiza conduta mais grave entre as várias previstas pelo legislador como elementares. Como bem jurídico foi lesionado de forma mais acentuada, a pena deve ser maior. É a situação do réu, que praticava a conduta com o objetivo de aferir lucro, com promessa de receber R\$5.000,00.

Diante dessas circunstâncias negativas, majoro a pena base em 2/5 do intervalo entre a pena mínima e máxima (ou seja, 10 anos), fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Verifico a atenuante da confissão, o que enseja redução da pena em 1/6. A pena intermediária é de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Incide a causa especial de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V), lembrando-se que para sua caracterização "é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587, STJ).

Esse elemento por si só justifica aumento da pena em 1/5, acima da fração mínima (1/6), por envolver não apenas o abastecimento de outro ponto de venda de drogas, mas também a articulação entre dois grupos criminosos e a consolidação de rotas da tráfico. Isso é especialmente sensível na Comarca, que fica nas margens da Rodovia Presidente Dutra, com todas as graves implicações sociais inerentes, exigindo-se maior repreensão pelo Estado.

Afasto a causa especial de aumento tráfico em transporte público (art. 40, III), considerando que não há prova de que o réu forneceu ou iria fornecer a droga aos demais passageiros, ou que a transportava de maneira ostensiva. Atualmente esse requisito é exigido pela jurisprudência.

Assim, a reprimenda é de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Sendo o réu primário e inexistente outra ação penal em curso, viável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). O fato de ter praticado tráfico interestadual não implica necessariamente que o réu integre organização criminosa, pois não se descarta que sua colaboração com o grupo tenha sido apenas eventual, ou pelo menos não há prova decisiva em sentido contrário. Contudo, ainda que de maneira esporádica, o réu tinha ciência que estava colaborando com grupos criminosos que fomentam o tráfico de maneira profissional, motivo pelo qual a redução deve ser feita no patamar mínimo (1/6).

Por isso, a reprimenda final é de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado. As circunstâncias desfavoráveis apontadas (50kg de maconha; ação que visava o lucro; tráfico interestadual) demonstram maior lesividade concreta do delito e exigem um agravamento do regime inicial para que a pena seja suficiente para a reprovação e prevenção (art. 33, §3º, CP).

Independentemente da quantidade da pena, tais circunstâncias subjetivas desfavoráveis também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CP).

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FRANCIMARIO NUNES DA COSTA como incurso no art. 33, §4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, na pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Mantenho a prisão preventiva.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas (50kg de maconha; ação que visava o lucro; tráfico interestadual) demonstram expressiva lesividade concreta da conduta, a justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, não existem alterações de fato ou de direito que infirmem os argumentos da decisão que decretou a segregação cautelar, que ora ficam reiterados. Na realidade, a prisão para a garantia da ordem pública se torna ainda mais necessária depois do

amplo contraditório e confirmação da culpa em sentença proferida com cognição exauriente. Com a condenação, eventual direito a progressão de regime poderá ser analisado pelo Juízo da Execução.

Expeça-se guia de execução, recomendando-se no estabelecimento penal em que se encontra.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos em favor da União (dinheiro) (art. 63, I e §1º, Lei 11.343/06).

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06) e comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Saem as partes intimadas em audiência. Cumpra-se.

Aruja, 26 de abril de 2022.